

罪数に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものを2個選びなさい。

1. 甲は、Aから財物を詐取した上で当該財物の返還を免れるためにAを殺害することを計画し、計画どおりにAから財物を詐取し、その後、殺意をもってAの胸部をナイフで刺して殺害し、これにより、財物の返還を免れるという財産上不法の利益を得た。甲には、詐欺罪と強盗殺人罪が成立し、これらは包括一罪となる。
2. 暴力団幹部甲は、配下の組員数名とともに、Aの身体に共同して危害を加える目的で、日本刀数本を準備してA方前に集合し、その直後、外に出てきたAの顔面を手拳で数回殴打する暴行を加えた。甲には、凶器準備集合罪と暴行罪が成立し、これらは併合罪となる。
3. 甲は、業務として猟銃を用いた狩猟に従事していた際、Aを熊と誤認して発砲し、Aに傷害を負わせ、その直後にAを誤射したことに気付いたが、Aを殺害して逃走しようと決意し、殺意をもってAの胸部に向けて発砲し、Aを即死させた。甲には、業務上過失傷害罪と殺人罪が成立し、これらは包括一罪となる。
4. 甲は、A銀行が発行したB名義のキャッシュカード1枚をBから窃取した上、これを利用してA銀行の現金自動預払機から預金を不正に払い戻した。甲には、2個の窃盗罪が成立し、これらは併合罪となる。
5. 甲は、対立する不良グループのメンバーA及びBを襲撃することを計画し、路上で発見したAをバットで1回殴打した直後、そばにいたBを同バットで1回殴打し、両名に傷害を負わせた。甲には、2個の傷害罪が成立し、これらは包括一罪となる。

No200	罪 数	正答率
共通R4-17	正 解 3、5 (順不同)	38%

1 正しい ★

最決昭 61.11.18 (百選Ⅱ40 事件) により、本記述は正しい。

判例は、本記述と類似の事案において、「被告人による拳銃発射行為は、……いわゆる2項強盗による強盗殺人未遂罪にあたるというべきであり……先行する覚せい剤取得行為がそれ自体としては、窃盗罪又は詐欺罪のいずれに当たるにせよ、前記事実関係にかんがみ、本件は、その罪と(2項)強盗殺人未遂罪のいわゆる包括一罪として重い後者の刑で処断すべき」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、財物そのものが詐欺罪により保護されるのと同様に、被害者の有する代金請求権も別個の保護に値するから、二罪の成立を認めるべきであるが、結局は同一の財産的利益であるから、包括一罪が成立するというを挙げている。したがって、本記述の甲には、詐欺罪と強盗殺人罪が成立し、これらは包括一罪となる。

2 正しい

最決昭 48.2.8 により、本記述は正しい。

凶器準備集合罪(208条の2第1項)は、「2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した」場合に成立する犯罪であるが、判例は、本罪と目的とされる犯罪(加害行為)との罪数につき、併合罪になるとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、本罪の公共危険罪の性格を重視すると、傷害罪などが成立しても法益が異なるということを挙げている。したがって、本記述の甲には、凶器準備集合罪と暴行罪が成立し、これらは併合罪となる。

3 誤っている

本記述は、甲には、業務上過失傷害罪と殺人罪が成立し、これらは包括一罪となるとしている点で、誤っている。

最決昭 53.3.22 (百選Ⅰ14 事件)。判例は、本記述と同様の事案において、業務上過失傷害罪と殺人罪が成立し、両罪は併合罪になるとしている。したがって、本記述の甲には、業務上過失傷害罪と殺人罪が成立し、これらは併合罪となる。

4 正しい

最判昭 25.2.24 により、本記述は正しい。

判例は、本記述と同様の事案において、窃取又は詐取した郵便貯金通帳により払戻名義の下に金員を詐取することは新たな法益侵害であるから、別個の犯罪が成立し、併合罪の関係に立つとしている。したがって、本記述の甲には、Bのキャッシュカード及びA銀行の預金に対する2個の窃盗罪が成立し、これらは併合罪となる。

5 誤っている

本記述は、甲には、2個の傷害罪が成立し、これらは包括一罪となるとしている点で、誤っている。

包括一罪とは、複数の犯罪が成立するようにみえるが、包括的な評価により全体が一罪として処断される場合をいう。判例は、包括一罪につき、法益侵害の一体性と行為の一体性などの観点を総合的に判断しているとされる。本記述では、被害者がAとBの別人であり、法益侵害の一体性が認められない。また、最決平 22.3.17 (百選Ⅰ102 事件) のように例外的に包括評価すべき事情もない。したがって、甲には、2個の傷害罪が成立し、これらは併合罪となる。

以上により、誤っている記述は3と5であり、したがって、正解は肢3と肢5(順不同)となる。